DATOS DEL PROCESO ARBITRAL

NRO. DE EXPEDIENTE : EXP. NRO. 14-2022-CCGC-CECARD/AYA.

MODALIDAD DE ARBITRAJE : Arbitraje Acelerado.

PARTES INTERVINIENTES :

Demandante : Consorcio Energy

Demandado : Gobierno Regional de Ayacucho

TRIBUNAL UNIPERSONAL : Abg. Carlos Christian Gonzales Cabello – Árbitro Único.

SECRETARIA ARBITRAL : Bach. Katherine Sheyla Flores Martínez

MATERIA DE CONTROVERSIA : Devolución de carta fianza y otros.

FECHA DE SOLICITUD : 09 de setiembre de 2022.

FECHA DE INSTALACION : 06 de octubre de 2022.

FECHA DE EMISION DE LAUDO : 24 de febrero de 2023.

ESCRITOS POST LAUDO : -

Centro de Conciliación Arbitraje y Resolución de Disputas - CECARD

CENTRO DE CONCILIACIÓN, ARBITRAJE Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS - CECARD

Caso Arbitral N° 14-2022-CCGC-CA-CECARD/AYA

CONSORCIO ENERGY

vs.

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

LAUDO

Tribunal Arbitral Unipersonal

Carlos Christian Gonzales Cabello

Secretaría Arbitral

Katherine Sheyla Flores Martínez

Lima, 24 de febrero de 2023

LISTA DE ABREVIATURAS

Nombre	Abreviatura
CONSORCIO ENERGY conformado por CORPORACIÓN KOMATSU INGENIEROS DEL PERÚ S.A.C y PERCY YON GONZALES CCOYA	DEMANDANTE o CONTRATISTA
GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO	DEMANDADA o ENTIDAD
Conjuntamente el DEMANDANTE y la DEMANDADA	LAS PARTES
Contrato N° 0154-2020-GRA-SEDE CENTRAL-OAPF DEL 28.10.2020 para la "Adquisición e Instalación del Sistema de Gases Medicinales, afecto a la Meta 099 de la obra: Reemplazo de la Infraestructura e Implementación de la Red de Salud Huamanga – Ayacucho"	CONTRATO o CONTRATO PRINCIPAL
Adjudicación Simplificada N° 081-2020-GRA-SEDE CENTRAL 2 derivada de la Licitación Púbica N° 001-2020-GRA-SEDE CENTRAL	PROCESO DE SELECCIÓN
ADENDA N° 001 al Contrato N° 0154-2020-GRA-SEDE CENTRAL-OAPF del 23.05.2022	ADENDA N° 01
TUO Ley N° 30225, "*Ley de Contrataciones del Estado*" aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF	LCE
Decreto Supremo N° 344-2018-EF, "*Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado*" y sus modificatorias	RLCE
Decreto Legislativo N° 1071, Ley que norma el arbitraje	LEY DE ARBITRAJE
CENTRO DE ARBITRAJE Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS - CECARD	CENTRO
Reglamento de Arbitraje del Centro de Arbitraje de CECARD	REGLAMENTO DEL CENTRO
Percy Yon Gonzales Ccoya	REPRESENTANTE DEL DEMANDANTE
Procurador Público Regional, Abog. Víctor Oriundo Medina	REPRESENTANTE DE LA DEMANDADA
Rayner Malqui García	ABOGADO DEL DEMANDANTE
Ellie Huamaní Huamaní	ABOGADO DE LA DEMANDADA

ÍNDICE

I.	DECLARACIÓN	4
II.	CONVENIO ARBITRAL	4
III.	CONSTITUCIÓN	4
IV.	LUGAR Y SEDE DEL ARBITRAJE	4
V.	TIPO DE ARBITRAJE	5
VI.	NORMATIVA APLICABLE	5
VII.	PRINCIPALES ACTUACIONES PROCESALES	5
VIII.	POSICIÓN DE LAS PARTES	6
VIII.1.	DEMANDA	6
VIII.2.	CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA	10
IX.	CUESTIONES CONTROVERTIDAS	13
X.	CONSIDERANDOS	14
XI.	PRIMERA PRETENSIÓN PRINCIPAL	16
XII.	SEGUNDA PRETENSIÓN PRINCIPAL	37
XIII.	TERCERA PRETENSIÓN PRINCIPAL	38
XIV.	PARTE RESOLUTIVA - FALLO	40

I. DECLARACIÓN

1. El Tribunal Arbitral Unipersonal declara haber revisado todos y cada uno de los medios probatorios aportados por LAS PARTES y admitidos dentro de este arbitraje, analizándolos y adjudicándoles el valor probatorio que les corresponde, aun cuando en el laudo no se haga mención expresa a alguno o algunos de ellos o al valor probatorio que le ha sido asignado.

2. En consecuencia, habiéndose cumplido con los presupuestos procesales y no existiendo vicio alguno que afecte la validez del presente proceso arbitral, el cual se ha desarrollado cumpliendo todas sus etapas, el Tribunal Arbitral Unipersonal emite el Laudo en el presente Arbitraje Nacional y de Derecho.

II. CONVENIO ARBITRAL

3. Con fecha 28 de octubre de 2020, el DEMANDANTE y la ENTIDAD suscribieron el CONTRATO, en cuya Clausula Décimo Octava se encuentra el convenio arbitral:

> **CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS**
>
> Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediar conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.
>
> Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
>
> Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas arbitraje.
>
> El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45° de la Ley de Contrataciones del Estado.

III. CONSTITUCIÓN

4. El Árbitro Único fue designado por el Consejo Superior de Arbitraje del CENTRO mediante carta notificada con fecha 28 de setiembre del 2022, la cual cumplió con aceptar en la misma fecha.

IV. LUGAR Y SEDE DEL ARBITRAJE

5. Se estableció como lugar del arbitraje la ciudad de Ayacucho y como sede institucional del arbitraje el local del CENTRO, ubicado en Jr. Carlos F. Vivanco Nro. 474 2do. Piso – Huamanga.

V. TIPO DE ARBITRAJE

6. El presente arbitraje es uno nacional y de derecho; en la modalidad de arbitraje acelerado.

VI. NORMATIVA APLICABLE

7. Para este arbitraje es aplicable la LEY DE ARBITRAJE y administrado de conformidad con el REGLAMENTO DEL CENTRO – Apéndice II - Reglas del Arbitraje Acelerado.

8. La normativa aplicable al fondo de la controversia es la LCE y el RLCE.

VII. PRINCIPALES ACTUACIONES PROCESALES

9. Con fecha 09 de setiembre de 2022, el DEMANDANTE solicitó el inicio de un Arbitraje Acelerado contra la ENTIDAD, a fin de solucionar las controversias surgidas en relación con el Contrato N° 0154-2020-GRA-SEDE CENTRAL-OAPF DEL 28.10.2020

10. El 16 de setiembre de 2022, la ENTIDAD respondió la solicitud de arbitraje.

11. Mediante la Resolución N° 1 de fecha 06 de octubre de 2022, se remitió a LAS PARTES la propuesta de reglas del proceso, se declaró instalado el Tribunal Arbitral Unipersonal y se otorgó a LAS PARTES el plazo de dos (2) días hábiles para que manifiesten lo conveniente a su derecho sobre las reglas propuestas.

12. Mediante Resolución N° 2 de fecha 11 de octubre de 2022 (rectificada mediante Resolución N° 3 de fecha 13 de octubre del 2022) se declaró consentidas las reglas del proceso y se otorgó el plazo de cinco (5) días para que el CONSORCIO presentara su demanda, con lo cual cumplió el 20 de octubre del 2022.

13. Mediante Resolución N° 4 de fecha 27 de octubre de 2022 se admitió a trámite la demanda y se corrió traslado a la ENTIDAD, otorgándole el plazo de cinco (5) días hábiles para pronunciarse, con lo cual cumplió con fecha 08 de noviembre del 2022.

14. Mediante Resolución N° 5 de fecha 10 de noviembre de 2022 se admitió a trámite la contestación de demanda, se fijó los puntos controvertidos, se admitió los medios probatorios ofrecidos por ambas partes y se les citó para la Audiencia Única.

15. Con fecha 18 de noviembre del 2022 se desarrolló la Audiencia Única con la participación de ambas partes quienes tuvieron la oportunidad de exponer sus puntos de vista sobre las controversias del caso.

16. Mediante Resolución N° 7 de fecha 25 de noviembre de 2022 se suspendió las actuaciones arbitrales por falta de pago de los honorarios arbitrales y gastos administrativos del CENTRO.

17. Mediante Resolución N° 8 de fecha 29 de diciembre de 2022 se ordenó el levantamiento de la suspensión arbitral y que se prosiga con las actuaciones arbitrales dado que el CONTRATISTA cumplió con el pago a su cargo. Asimismo, se le facultó para cumplir con realizar en subrogación el pago correspondiente a la ENTIDAD, bajo apercibimiento de una nueva suspensión del proceso arbitral.

18. Mediante Resolución N° 9 de fecha 10 de enero de 2023 se suspendió nuevamente el proceso por falta de pago, suspensión que se levantó mediante Resolución N° 10 de fecha 01 de febrero de 2023, otorgando además el plazo de cinco (5) días a LAS PARTES para que presentes sus alegatos finales con lo cual cumplió el CONTRATISTA con fecha 03 de febrero del 2023 y la ENTIDAD con fecha 08 de febrero del 2023.

19. Finalmente, mediante Resolución N° 11 de fecha 09 de febrero de 2023 se admitió a trámite los escritos de alegatos finales presentados por LAS PARTES y se declaró cerradas las actuaciones arbitrales, fijando el plazo para laudar en diez (10) días hábiles prorrogables por cinco (05) días hábiles conforme lo faculta el literal e. del artículo 2° del ANEXO II – REGLAS DEL ARBITRAJE ESPECIAL del REGLAMENTO del CENTRO.

VIII. POSICIÓN DE LAS PARTES

VIII.1. DEMANDA

20. Con fecha 20 de octubre del 2022 el CONTRATISTA presentó su demanda arbitral y formuló las siguientes pretensiones:

> **Primera Pretensión Principal:** Que, se ordene al Gobierno Regional de Ayacucho cumplir con devolver la Carta Fianza N° 00024660 emitida por la Financiera Credinka por el monto de S/ 11,794.67 y sus respectivas renovaciones, otorgada a favor de la Entidad como garantía de fiel cumplimiento para la aprobación del adicional N° 01al Contrato N° 154-2020-GRA- SEDE CENTRAL – OAPF.
>
> **Segunda Pretensión Principal:** Que el Tribunal Arbitral Unipersonal ordene a la Entidad pagar a favor del Consorcio los mayores costos de renovación de carta fianza otorgada como garantía de fiel cumplimiento.
>
> **Tercera Pretensión Principal:** Que, Determinar la Entidad pague las costas y costos asumidos por el Consorcio Energy en el presente proceso arbitral.

21. Según sus argumentos, con fecha 28 de octubre del 2020 ambas partes suscribieron el Contrato N° 154-2020-GRA-SEDE CENTRAL-OAPF, para la "Adquisición e Instalación del Sistema de Gases Medicinales, afecto a la Meta 099 de la Obra: Reemplazo de la Infraestructura e Implementación de la Red de Salud de Huamanga - Ayacucho" derivado de la Adjudicación Simplificada N° 081-2020-GRA- SEDE CENTRAL-2, derivada de la Licitación Pública N° 001-2020-GRA-SEDE CENTRAL.

22. El monto contractual ascendió a S/. 472,000.00 (Cuatrocientos Setenta y Dos Mil con 00/100 soles) bajo el Sistema de Contratación a Suma Alzada y un plazo de ejecución 80 días calendario, a partir del 29 de octubre del 2020.

Sobre la Primera Pretensión de la demanda

23. El CONTRATISTA señala que otorgó como garantía de fiel cumplimiento la Carta Fianza N° 010621419-00 emitida por el Banco Scotiabank, por la suma de S/47,200.00.

24. Seguidamente, mediante Resolución Gerencial General N° 192-2022-GRA/GR-GG, de fecha 27 de abril de 2022, se aprobó la ejecución de prestaciones adicionales al CONTRATO por el monto de S/ 117,946.70. Para ello, se dispuso que el CONTRATISTA cumpla con ampliar la garantía de fiel cumplimiento, ello de conformidad con lo establecido en el Art. 157° del RLCE.

25. Para la suscripción de la Adenda N° 01 al CONTRATO, cuyo objeto fue incorporar la prestación adicional al referido contrato aprobado por el monto de S/ 117,946.70, señala el CONTRATISTA que otorgó como garantía de fiel cumplimiento la Carta Fianza N° 00024660 emitida por la Financiera Credinka por el monto de S/ 11,794.67, ello en cumplimiento de lo establecido en la LCE.

26. El CONTRATISTA admite que no cumplió en renovar oportunamente la Carta Fianza N° 010621419-00 emitida por el Banco Scotiabank, por la suma de S/ 47,200.00, otorgado para la suscripción del CONTRATO. Ante ello, la ENTIDAD dispuso la ejecución de la referida carta, conforme se dispone en la LCE. Dicha situación no fue objetada por el CONTRATISTA debido a que correspondía su ejecución; estando vigente únicamente la Carta Fianza N° 00024660 emitida por la Financiera Credinka por el monto de S/ 11,794.67, otorgada como garantía para la suscripción de la adenda.

27. Señala también que por razones ajenas a su voluntad no pudo concluir la ejecución del servicio en su totalidad, razón por la que mediante Carta Notarial N° 81-2022-GRA/GG-ORADM del 15 de junio del 2022 la ENTIDAD resolvió parcialmente el CONTRATO.

28. Asimismo, mediante Carta Notarial N° 94-2022-GRA/GG-ORADM, se precisa los alcances de la resolución parcial de CONTRATO y, a consecuencia de ello, el CONTRATISTA solicitó el pago por la ejecución efectiva del CONTRATO.

29. Posterior a ello, previa verificación, el área usuaria validó lo indicado por el CONTRATISTA y procedió a otorgarles la conformidad por la prestación efectivamente realizada, señalando que les correspondía el pago de la suma S/ 350,070.30 correspondiente al CONTRATO PRINCIPAL y S/ 96,646.70 del adicional del CONTRATO.

30. Posteriormente, siendo que la causa para la resolución del CONTRATO era atribuible al CONTRATISTA, la ENTIDAD le aplicó la penalidad máxima en los pagos solicitados, los cuales ascendieron a la suma de S/ 47,200.00, correspondiente al contrato principal y S/11,794.67, correspondiente al adicional, los que fueron deducidos en los pagos efectuados.

31. En ese sentido, para el pago del Adicional N° 01, la ENTIDAD generó la Orden de Compra N° 1302 de fecha 25 de mayo de 2022, por el monto de S/ 117,946.70, con Exp. SIAF N° 4781 y le descontó la suma de S/ 11,794.67, entendiéndose que ésta correspondía a la aplicación de penalidad por mora (lo cual acepta).

32. Asimismo, respecto al contrato principal, la ENTIDAD retuvo la suma de S/ 47,200.00, haciendo un total entre ambas retenciones de S/ 58,994.67.

33. Para el caso del CONTRATO PRINCIPAL, el CONTRATISTA señala que correspondía que se le pague el monto íntegro, toda vez que la garantía de fiel cumplimiento ya había sido ejecutada. Dicho error fue subsanado por la ENTIDAD ya que el monto ejecutado fue devuelto posteriormente.

34. Menciona el CONTRATISTA que la ENTIDAD cumplió con retener el 10% del monto contractual del adicional aprobado, ante ello, señala que correspondía que le realice la devolución de la Carta Fianza N° 00024660 emitida por la Financiera Credinka por el monto de S/ 11,794.67, otorgada como garantía para la suscripción de la adenda.

35. Mediante Carta N° 041-2022-CE, el CONTRATISTA solicitó la devolución de la Carta Fianza N° 00024660, toda vez que la ENTIDAD cumplió con retener el 10% del monto contractual (prestación adicional), por lo que correspondía su devolución; sin embargo, ello no ocurrió, ya que mediante Carta N° 224-2022-GRA/GG-ORADM y Carta N° 238-2022-GRA/GG-ORADM, comunicó al CONTRATISTA la improcedencia de su solicitud, basándose en el Informe N° 062-2022/GRA-GG-ORADM-OAPF-UPL-MVRM e Informe N° 071-2022/GRA-GG-ORADM-OAPF-UPL-MVRM, suscrito por la funcionaria responsable de penalidades, quien

recomendó ejecutar la carta fianza a pesar de que la ENTIDAD retuvo el 10% del monto contractual en el pago final.

36. Respecto al informe suscrito por la responsable de Penalidades, el CONTRATISTA manifiesta que ésta carece de sustento legal, toda vez que funda en un supuesto daño causado a la ENTIDAD, recomendando su ejecución a fin de resarcir los daños causados a la ENTIDAD.

37. Argumenta el CONTRATISTA que el OSCE, en múltiples opiniones ha indicado que las garantías, cumplen una doble función: **compulsiva** y **resarcitoria**. Serán compulsivas, puesto que pretendían compeler u obligar al contratista a cumplir con todas sus obligaciones contractuales, bajo apercibimiento de ejecutar las garantías presentadas por este; asimismo, serán **resarcitorias**, puesto que pretendían, con su ejecución, indemnizar a la Entidad por los eventuales daños que hubiera sufrido debido al incumplimiento del contratista.

38. Según el CONTRATISTA, puede que exista un daño a la ENTIDAD a causa de la resolución del CONTRATO, como lo manifiesta la responsable de penalidades de la ENTIDAD; sin embargo, considera que, al aplicarse la penalidad máxima, en cumplimiento de la función resarcitoria de la garantía, se están reparando estos posibles daños. Asimismo, precisa que la referida funcionaria no sería competente para calificar si se causó o no perjuicio a la ENTIDAD, ya que sus funciones se limitan a realizar el cálculo y aplicación de penalidades, los cuales deberían realizarse conforme a las disposiciones señaladas en la LCE y el RLCE. Dicha facultad para determinar si se causó daño a la ENTIDAD, lo puede emitir un Juez o un árbitro, mas no así la responsable de penalidades.

Sobre la Segunda Pretensión de la demanda

39. Respecto a esta pretensión, el CONTRATISTA considera que la ENTIDAD, de manera arbitraria, se niega a la devolución de la Carta Fianza N° 00024660 emitida por la Financiera Credinka por el monto de S/ 11,794.67, otorgada como garantía para la suscripción de la adenda, incluso, recomienda su ejecución.

40. Asimismo, señala para que no se ejecute la carta fianza otorgada se ha visto obligada a tener que renovarla, ya que, de no hacerlo, podía generar que se ordene su ejecución causando perjuicios irreparables para la empresa, pues todas las entidades financieras negarán la emisión de fianzas lo que derivará en la imposibilidad de seguir contratando con el Estado y, además, se estarían ejecutando las garantías dejadas en la entidad financiera para la emisión de la carta fianza.

Sobre la Tercera Pretensión de la demanda

41. Respecto a esta pretensión, el CONTRATISTA señala que al haberse acreditado que corresponde la devolución de la carta fianza y la actuación arbitraria de la ENTIDAD de negarse a devolverla, obligándolo a renovarla, corresponde que se condene a la ENTIDAD con el pago de las costas y costos asumidos, toda vez que le viene generando perjuicios económicos y obligándolo a acudir a un arbitraje para la devolución de una carta fianza cuyo monto es similar a los honorarios arbitrales.

VIII.2. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA

42. El 08 de noviembre del 2022 la ENTIDAD presentó su contestación de demanda arbitral refutando los argumentos de su contraparte.

Sobre la Primera Pretensión de la Demanda

43. La ENTIDAD sostiene que su decisión de ejecutar la carta fianza de manera adicional a aplicar la penalidad es conforme a lo establecido en la LCE y el RLCE respecto a las cartas fianzas y/o garantías y penalidades de acuerdo a lo establecido en los siguientes artículos:

> ***"Artículo 32 LCE. El contrato***
> *32.3 Los contratos regulados por la presente norma incluyen necesariamente y bajo responsabilidad las cláusulas referidas a: a) Garantías, b) Anticorrupción, c) Solución de controversias y d) Resolución de contrato por incumplimiento, conforme a lo previsto en el reglamento. (… ".*
>
> ***"Artículo 33 LCE. Garantías***
> *33.1 Las garantías que deben otorgar los postores adjudicatarios y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.*
> *Sus modalidades, montos, condiciones y excepciones son regulados en el reglamento.*
> *33.2 Las garantías que acepten las Entidades deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país, al solo requerimiento de la respectiva Entidad, bajo responsabilidad de las empresas que las emiten. Dichas empresas deben encontrarse bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.*
> *33.3 En virtud de la realización automática, a primera solicitud, las empresas emisoras no pueden oponer excusión alguna a la ejecución de las garantías debiendo limitarse a honrarlas de inmediato dentro del plazo máximo de tres (3) días hábiles. Toda demora genera responsabilidad solidaria para el emisor de la garantía y para el postor o contratista, y da lugar al pago de intereses legales en favor de la Entidad. (…)."*

> ***"Artículo 149 RLCE. Garantía de fiel cumplimiento***
> *149.1. Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador entrega a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista, en el caso de bienes, servicios en general y consultorías en general, o hasta el consentimiento de la liquidación final, en el caso de ejecución y consultoría de obras."*
>
> ***"Artículo 155 RLCE. Ejecución de garantías***
> *155.1 Las garantías se ejecutan en los siguientes supuestos:*
> *a) Cuando el contratista no la hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento. Una vez que se cuente con la conformidad de la recepción de la prestación o haya quedado consentida la liquidación, según corresponda, y siempre que no existan deudas a cargo del contratista o de haber saldo a favor, se le devuelve el monto ejecutado sin dar lugar al pago de intereses. Tratándose de las garantías por adelantos, no corresponde devolución alguna por el adelanto pendiente de amortización.*
> *b) La garantía de fiel cumplimiento se ejecuta, en su totalidad, cuando la resolución por la cual la Entidad resuelve el contrato por causa imputable al contratista haya quedado consentida o cuando por laudo arbitral se declare procedente la decisión de resolver el contrato. En estos supuestos, el monto de la garantía corresponde íntegramente a la Entidad, independientemente de la cuantificación del daño efectivamente irrogado."*
>
> ***"Artículo 166 RLCE. Efectos de la resolución***
> *166.1. Si la parte perjudicada es la Entidad, esta ejecuta las garantías que el contratista hubiera otorgado sin perjuicio de la indemnización por los mayores daños irrogados."*

44. Para la ENTIDAD, esta regulación normativa concordante con las Opiniones OSCE N° 015-2018/DTN y N° 001-2019/DTN permite concluir que la principal función de la garantía de fiel cumplimiento es la de cautelar el logro del objeto contractual; en consecuencia, ante un incumplimiento del CONTRATO por parte del CONTRATISTA, esta garantía servía de medio para compensar a la ENTIDAD; y habiendo quedado consentida la resolución de contrato por causas atribuibles al CONTRATISTA, la ENTIDAD estaba en toda la facultad de ejecutar la carta fianza de fiel cumplimiento bajo los parámetros normativos transcritos líneas arriba.

45. Por otro lado, precisa que el RLCE regula lo referente a las penalidades, las cuales, son de naturaleza completamente diferente y ajena a las garantías.

> ***"Artículo 161. Penalidades***
> *161.1. El contrato establece las penalidades aplicables al contratista ante el incumplimiento injustificado de sus obligaciones contractuales a partir de la información brindada por el área usuaria, las mismas que son objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria.*

161.2. La Entidad prevé en los documentos del procedimiento de selección la aplicación de la penalidad por mora; asimismo, puede prever otras penalidades. Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.
161.3. En el caso de obras, dentro de las otras penalidades que se establezcan en los documentos del procedimiento, incluyen las previstas en el capítulo VI del presente título.
161.4. Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta, de las valorizaciones, del pago final o en la liquidación final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento."

"Artículo 162 RLCE. Penalidad por mora en la ejecución de la prestación
162.1. En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula:
Penalidad diaria = 0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en días
Donde F tiene los siguientes valores:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general, consultorías y ejecución de obras: F 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta (60) días:
b.1) Para bienes, servicios en general y consultorías:
F = 0.25
B.2) Para obras: F = 0.15
162.2. Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al monto vigente del contrato o ítem que debió ejecutarse o, en caso que estos involucraran obligaciones de ejecución periódica o
entregas parciales, a la prestación individual que fuera materia de retraso."

46. Señala la ENTIDAD que, según la normativa, las penalidades son aplicadas al CONTRATISTA ante el incumplimiento de sus obligaciones contractuales y/o ante el retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato las que se aplican automáticamente por cada día de atraso y son deducidas del pago final o de los pagos a cuenta, según corresponda, como se ha concluido también en las Opiniones del OSCE:

> ***OPINIÓN Nº 015-2018/DTN:***
>
> ***3. CONCLUSIONES***
>
> *3.1 Cuando el contratista se retrasaba injustificadamente en el cumplimiento de las prestaciones a su cargo, la Entidad le aplicaba una penalidad por mora, la cual debía ser deducida del pago final o de los pagos a cuenta, cuando correspondía; o en caso sea necesario, del monto resultante de la ejecución de las garantías presentadas por el contratista.*
>
> *3.2 En caso se hubiera llegado a acumular el monto máximo de penalidad por mora o el monto máximo de otras penalidades, la Entidad se encontraba en la facultad de resolver el contrato por incumplimiento, supuesto en el cual ejecutaba la garantía de fiel cumplimiento, siempre que dicha resolución hubiera quedado consentida.*
>
> *3.3 Si la Entidad procedió a resolver el contrato al haberse llegado a acumular el monto máximo de penalidad por mora y ante ello ejecuta la garantía de fiel cumplimiento por dicha resolución sin que se haya podido cobrar el monto de la penalidad, la ejecución de la garantía no puede usarse para amortizar la referida penalidad, correspondiendo a la Entidad solicitar el pago de dicha penalidad al proveedor.*

> ***OPINIÓN Nº 001-2019/DTN***
>
> ***3. CONCLUSIÓN***
>
> *3.2 Cuando un contrato ha sido resuelto -total o parcialmente- por causas imputables al contratista, y esta resolución ha quedado consentida, la Entidad se encuentra facultada para ejecutar, en su totalidad, la garantía de fiel cumplimiento que se hubiera otorgado, sin tener en cuenta la naturaleza de la prestación incumplida que motivó dicha resolución.*

47. La ENTIDAD asegura que la ejecución de la carta fianza de fiel cumplimiento obedece a lo taxativamente establecido en la normativa de la materia y se encuentra debidamente sustentada con el consentimiento de la resolución de contrato efectuada por la ENTIDAD; así como la aplicación de la penalidad máxima por mora según el cálculo de la especialista y no refutada por el CONTRATISTA conforme lo ha señalado en el numeral 8. de su propio escrito de demanda.

48. Respecto al argumento de que la responsable de penalidades no es competente para calificar si se causó o no perjuicio a la ENTIDAD que justifique la ejecución de la carta fianza de fiel cumplimiento; señala que la garantía de fiel cumplimiento se ejecuta, en su totalidad, cuando la resolución por la cual la Entidad resuelve el contrato por causa imputable al contratista haya quedado consentida, independientemente de la cuantificación del daño efectivamente irrogado; en ese sentido, debe desestimarse el argumento de que es un juez o árbitro los llamados a determinar si se causó o no daño a la ENTIDAD.

Sobre la Segunda y Tercera Pretensiones de la Demanda

49. Para la ENTIDAD, siendo que la ejecución de la carta fianza es válida y procedente, la demanda carece de todo sustento fáctico y jurídico por lo que sus pretensiones no merecen ser estimadas y, en consecuencia, tampoco correspondería que se conmine a la demandada el pago de las costas y costos que está acarreando el presente proceso arbitral.

IX. CUESTIONES CONTROVERTIDAS

50. Mediante Resolución N° 5 de fecha 10 de noviembre del 2022 se determinó las materias de pronunciamiento del Árbitro Único:

> ***"Primera Cuestión controvertida:***
> *Determinar si corresponde que el Tribunal Arbitral Unipersonal ordene al Gobierno Regional de Ayacucho cumplir con devolver la Carta Fianza N° 00024660 emitida por la Financiera Credinka por el monto de S/ 11,794.67 y sus respectivas renovaciones, otorgada a favor de la Entidad como garantía de fiel cumplimiento para la aprobación del adicional N° 01al Contrato N° 054-2020-GRA- SEDE CENTRAL – OAPF."*
>
> ***"Segunda Cuestión controvertida:***
> *Determinar si corresponde que el Tribunal Arbitral Unipersonal ordene a la Entidad pagar a favor del Consorcio los mayores costos de renovación de carta fianza otorgada como garantía de fiel cumplimiento."*
>
> ***Tercera Cuestión controvertida:***
> *"Determinar si corresponde que el Tribunal Arbitral Unipersonal ordene a la Entidad el pago de las costas y costos asumidos por el Consorcio Energy en el presente proceso arbitral. "*

X. CONSIDERANDOS:

51. Antes de entrar a analizar la materia controvertida, resulta pertinente confirmar lo siguiente:

    (i) El Tribunal Arbitral Unipersonal se constituyó de acuerdo al convenio arbitral celebrado por LAS PARTES.

    (ii) En ningún momento se impugnó o reclamó contra las disposiciones de procedimiento dispuestas en las Reglas del Proceso.

    (iii) El DEMANDANTE presentó su escrito de demanda arbitral dentro del plazo dispuesto en las reglas del proceso.

(iv) LA DEMANDADA fue debidamente emplazada con la demanda, la contestó y ejerció plenamente su derecho de defensa y contradicción.

(v) LAS PARTES tuvieron plena oportunidad para ofrecer todos sus medios probatorios.

(vi) El Árbitro Único deja constancia de que, en el estudio, análisis del presente Laudo Arbitral, se han tenido en cuenta todos los argumentos y las alegaciones efectuadas por LAS PARTES, así como todos los medios probatorios aportados, efectuándose un análisis y una valoración en conjunto de los mismos, de manera que la no referencia a un argumento o a una prueba no supone que no haya sido tomado en cuenta para su decisión.

(vii) De otro lado, el Árbitro Único considera importante tener en cuenta que los medios probatorios deben tener por finalidad acreditar los hechos expuestos por LAS PARTES, producir certeza en el Tribunal Arbitral respecto a los puntos controvertidos y fundamentar las decisiones, conforme a los principios generales de la prueba: necesidad, originalidad, pertinencia y utilidad. Los medios probatorios deben ser valorados por el Tribunal Arbitral de manera conjunta, utilizando su apreciación razonada, y si no se prueban los hechos que fundamentan sus pretensiones, éstas deberán ser declaradas infundadas.

(viii) Asimismo, con relación a las pruebas aportadas, en aplicación del Principio de Comunidad de la Prueba, las pruebas ofrecidas por LAS PARTES, desde el momento que fueron presentadas y admitidas como medios probatorios, pasaron a pertenecer al presente arbitraje y, por consiguiente, pueden ser utilizadas para acreditar hechos que incluso vayan en contra de los intereses de la parte que las ofreció.

(ix) Los hechos a los que se refiere el análisis del caso son los establecidos en los Antecedentes, en concordancia con la información que obra en los actuados del proceso, así como los que se mencionan en los demás acápites del presente Laudo Arbitral.

(x) Este Árbitro Único, conforme lo establecido en el Artículo 139° numeral 1 de la Constitución Política del Perú, ejerce función jurisdiccional y, por lo tanto, no se encuentra subordinado a ningún órgano administrativo o de cualquier otra índole, ejerciendo sus funciones con absoluta independencia, en el marco de las competencias que son propias a su naturaleza.

(xi) En el análisis de las pretensiones de este Laudo Arbitral, el Tribunal Arbitral Unipersonal se ha reservado el derecho de seguir el orden

que estima más conveniente para la solución de las controversias contenidas en los puntos controvertidos del presente caso arbitral.

(xii) El Árbitro Único está procediendo a emitir el Laudo Arbitral dentro del plazo que corresponde a las reglas de este proceso.

ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES CONTROVERTIDAS

52. Que, debe precisarse que, los puntos controvertidos constituyen una referencia para el análisis que debe efectuar el Árbitro Único, pudiendo en consecuencia realizar un análisis conjunto de los mismos en aquellos casos en los que se encuentren íntimamente ligados, por lo que, en ese sentido, el Árbitro Único considera que el análisis debe realizarse de acuerdo a la forma siguiente:

XI. <u>SOBRE LA PRIMERA CUESTIÓN CONTROVERTIDA</u>:

- **Primera Cuestión Controvertida derivada de la Primera Pretensión Principal:**

  "Determinar si corresponde que el Tribunal Arbitral Unipersonal ordene al Gobierno Regional de Ayacucho cumplir con devolver la Carta Fianza N° 00024660 emitida por la Financiera Credinka por el monto de S/ 11,794.67 y sus respectivas renovaciones, otorgada a favor de la Entidad como garantía de fiel cumplimiento para la aprobación del adicional N° 01al Contrato N° 054-2020-GRA- SEDE CENTRAL – OAPF."

POSICIÓN DEL CONTRATISTA

53. La posición del CONTRATISTA respecto a esta Primera Cuestión Controvertida derivada de la Primera Pretensión Principal, según lo plasmado en su demanda arbitral, ha sido expuesta en los Considerandos 20 al 41 del presente laudo arbitral.

54. Asimismo, con fecha 03 de febrero del 2023 el CONTRATISTA presentó su escrito de Alegatos Finales en el cual reiteró los argumentos de su demanda arbitral.

POSICIÓN DE LA ENTIDAD

55. La posición de la ENTIDAD respecto a esta Primera Cuestión Controvertida derivada de la Primera Pretensión Principal, según lo plasmado en su demanda arbitral, ha sido expuesta en los Considerandos 43 al 49 del presente laudo arbitral.

56. Asimismo, con fecha 08 de febrero del 2023 la ENTIDAD presentó su escrito de Alegatos Finales en el cual reiteró los argumentos de su contestación de demanda.

POSICIÓN DEL ÁRBITRO ÚNICO

SOBRE EL CONTRATO

57. El Árbitro Único considera oportuno iniciar mencionando que el contrato es el acuerdo de dos o más partes para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial y reconocido así por nuestro Código Civil en su artículo 1351°.

58. Seguidamente, debemos considerar que, conforme lo establece el artículo 1361° del mismo cuerpo normativo, los contratos son obligatorios en cuanto se haya expresado en ellos y presume que la declaración expresada en el contrato responde a la voluntad común de las partes y quien niegue esa coincidencia debe probarlo. Por ende, el primer efecto que causa el contrato radica en su carácter obligatorio, es decir, el acuerdo de voluntades de las partes contratantes tiene fuerza de ley entre ellas, por lo que ninguna de las partes podrá sustraerse al deber de observar el mismo contrato, sino que ha de cumplirlo y respetar la palabra empeñada (*pacta sunt servanda*)[1]. La *lex contractus* es una ley autónoma, son preceptos que se da cada contratante, a tenor del compromiso que suscribe, vinculándose a una conducta: actuar a través de un dar o un hacer o abstenerse de hacerlo. El contrato es, sin duda, la fuente principal de las obligaciones conforme lo establecido con el artículo 1351° del Código Civil[2].

59. Por su parte el artículo 1362° del Código Civil establece lo siguiente:

> ***"Artículo 1362°.-***
> *Los contratos deben negociarse, celebrarse y ejecutarse según las reglas de la buena fe y común intención de las partes."*

60. La Buena Fe, piedra angular de las relaciones contractuales, contenida en el artículo *ut supra* citado, es una Cláusula General Normativa en disposición de suplir vacíos legales u orientar al correcto interpretar de comportamientos acorde a Derecho; sin embargo, ello no es mérito de ser considerada como fuente de obligaciones contractuales.

61. En ese sentido, en nuestro ordenamiento jurídico la Buena Fe no genera obligaciones para las partes ni mucho menos genera una tercera partición de la Responsabilidad Civil (Responsabilidad Pre-Contractual), como sí pudiese ser en otros sistemas (v.g. Alemania).

---

[1] **PÉREZ GALLARDO, Leonardo.** "Código Civil Comentado. Tomo VII – Contratos en General". Gaceta Jurídica-2007, pág. 90.
[2] **LACRUZ BERDEJO, José Luis.** "Elementos del Derecho Civil II – Derecho de Obligaciones". Volumen 2° Teoría General del Contrato. Barcelona, 1987, pp. 317-318

62. En efecto, nuestro ordenamiento jurídico solo prevé dos tipos de responsabilidades: (1) responsabilidad por incumplimiento de obligaciones y (2) la responsabilidad extracontractual. Donde en el primer supuesto, se responde por la inejecución de una prestación a su cargo, incurriendo en una inejecución total o parcial, tardía o defectuosa de la prestación. Mientras que en el segundo supuesto sería por el sometimiento a la sanción que el ordenamiento jurídico prevé contra los actos ilícitos civiles, lesivos a los intereses de las personas, y más específicamente, lesivos de la integridad de las situaciones jurídicas subjetivas protegidas *erga omnes* por el ordenamiento[3].

63. Ahora bien, los contratos que suscriben las entidades, así como lo que realizan los particulares, tienen como objetivo la satisfacción del interés del acreedor. A partir de ello, el cumplimiento de las prestaciones, está destinado a que el deudor pueda entregar lo que se ha comprometido[4]. En estos casos, el acreedor busca conseguir un objetivo final con su contratación, para lo cual se le otorga un carácter patrimonial, en tanto se paga una contraprestación[5].

64. Analizar este tema es importante, ya que toda relación obligatoria versa sobre la satisfacción de intereses. Sería irrelevante que existiesen contratos sobre bienes que las partes poseen en abundancia o que no presenten cambios en las relaciones económicas de utilidad, ya que no existiría interés de ser cumplido[6]. Conforme señala FERNANDEZ CRUZ, son las partes las que le otorgan, dentro de un ambiente jurídico-social, la valoración de los intereses[7] y el objetivo de cualquier obligación que se pacte es la satisfacción del interés del acreedor[8].

65. Por su parte, ÁLVAREZ PEDROZA[9] sostiene que, dentro de la normativa de contrataciones con el Estado, los contratos perfeccionados dentro del proceso de contratación son obligatorios para las partes y no puede formalizarse o perfeccionarse sin la cláusula de contraprestación, por lo cual este contrato siempre será a título oneroso. Los sujetos de la relación contractual (entidad y contratista) asumen una obligación frente a la otra y viceversa. La entidad, como el contratista, se vincula

---

[3] **LEÓN HILARIO, Leysser.** "*La responsabilidad extracontractual (Apuntes para una introducción al estudio del modelo jurídico peruano)*, en ID., *La responsabilidad civil - Líneas fundamentales y nuevas perspectivas*, 2ª. ed. Jurista Editores, Lima, 2007, p. 50.
[4] **BIANCA, Massimo.** El interés. Traducción de Gastón Fernández Cruz. Lima: Ius et veritas, p.111. "El interés del acreedor es el interés que la prestación está destinada a satisfacer. Esta idea de la necesidad de cooperación ajena de fondo de la obligación".
[5] **BARCHI VELOACHAGA, Luciano**. Introducción al Estudio del Derecho de obligaciones. Lima: PUCP, d.27. "Una relación jurídica será patrimonial cuando versa sobre bienes o intereses que poseen naturaleza económica. los bienes y los intereses poseen naturaleza económica cuando pueden ser objeto de valorización".
[6] **BARCHI VELOACHAGA, Luciano.** La relación obligatoria: Tema 2. Lima: PUCP, d, 8
[7] **FERNANDEZ CRUZ, Gastón.** La obligación: Apuntes para una dogmática jurídica del concepto. Lima: Themis. Vol. 38. 1998, p, 51
[8] **PALACIOS MARTÍNEZ, Eric.** Cumplimiento del tercero, oposición del deudor y derecho a la liberación. N° 58. En: DERECHO PUC. Lima: Perú, p, 88.
[9] **ALVAREZ PEDROZA, Alejandro.** "Análisis de la ley y Reglamento de Contrataciones del Estado – Volumen 2. Ediciones Gubernamentales. Lima, 2013. Pág. 82.

a través de un contrato de obligaciones o prestaciones recíprocas (bilateral o sinalagmáticas) que se clasifican por el objeto de contratación en categorías genéricas de "dar" y/o "hacer", correspondiendo al cumplimiento de la prestación, una contraprestación. En este orden de ideas, no existe duda alguna que el contrato que celebran los sujetos de la relación contractual (entidad y contratista), es uno de obligaciones recíprocas, de entrega de prestación y contraprestación.

66. Además de lo mencionado, debe tenerse en cuenta que este tipo de contratos se conforman, de acuerdo con el RLCE, con el documento que lo contiene, las Bases Integradas y la Oferta Ganadora, así como los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes que hayan sido expresamente señalados en el contrato.

El CONTRATO BAJO ANÁLISIS

67. En el presente proceso arbitral se analizan las controversias surgidas de la ejecución del Contrato N° 0154-2020-GRA-SEDE CENTRAL-OAPF DEL 28.10.2020 para la "Adquisición e Instalación del Sistema de Gases Medicinales, afecto a la Meta 099 de la obra: Reemplazo de la Infraestructura e Implementación de la Red de Salud Huamanga – Ayacucho", derivado de la Adjudicación Simplificada N° 081-2020-GRA-SEDE CENTRAL 2 derivada de la Licitación Púbica N° 001-2020-GRA-SEDE CENTRAL, con un monto total ascendente a S/. 472,000.00 (Cuatrocientos Setenta y Dos Mil con 00/100 soles).

68. Seguidamente, del análisis de los medios probatorios aportados al proceso tenemos la siguiente cronología de los hechos relevantes:

- ✓ **28.10.2020.** Suscripción del CONTRATO.
- ✓ **23.09.2021.** Mediante Carta Notarial N° 98-2021-GRA/GG-ORAM la ENTIDAD resuelve el CONTRATO por acumulación de la penalidad máxima del 10% del monto contractual por retraso injustificado.
- ✓ **15.11.2021.** Acuerdo conciliatorio entre LAS PARTES mediante el cual la ENTIDAD deja sin efecto la resolución del CONTRATO, el CONTRATISTA acepta la aplicación de la penalidad máxima del 10% del monto contractual por retraso injustificado y la ENTIDAD otorga 40 días calendario más para la culminación de las actividades.
- ✓ **27.04.2022.** Mediante Resolución General N° 192-2022-GRA/GR-GG la ENTIDAD aprueba la ejecución de prestaciones adicionales al CONTRATO por el importe de S/ 117,946.70 y se solicita al CONTRATISTA la ampliación proporcional de las garantías.
- ✓ **19.05.2022.** El CONTRATISTA cumple con presentar la Carta Fianza N° 00024660 emitida por la Financiera Credinka por el

monto de S/ 11,794.67, para la elaboración de Prestaciones Adicionales.

- ✓ **23.05.2022.** Se suscribe la ADENDA N° 001.
- ✓ **06.06.2022.** Mediante Informe N° 042-2022-GRA/GG-ORADM-OAPF-UPL-MVRM la Responsable de Penalidades en Licitaciones determina que el CONTRATISTA incurrió nuevamente en incumplimiento a sus obligaciones contractuales, recomendó la aplicación máxima de la penalidad ascendente 10% del monto contractual (S/ 47,200.00). Asimismo, recomienda resolver el CONTRATO y ejecutar la Carta Fianza N° 010621419-00 emitida por el Banco Scotiabank, por la suma de S/47,200.00.
- ✓ **07.06.2022.** Mediante Informe N° 408-2022-GRA/GG-GRI-SGO-MABE-RO, el Residente de Obra solicita al Sub-Gerente de Obra la resolución parcial del CONTRATO.
- ✓ **16.06.2022.** Mediante Opinión Legal N° 85-2022-GRA/GG-ORAJ-LPD se recomienda la resolución parcial del CONTRATO por incumplimiento injustificado de obligaciones contractuales y ejecutar las garantías que hubiera otorgado, sin perjuicio de la correspondiente indemnización por los mayores gastos irrogados.
- ✓ **16.06.2022.** Mediante Carta Notarial N° 81-2022-GRA/GG-ORADM la ENTIDAD comunica al CONTRATISTA la resolución parcial del CONTRATO.
- ✓ **17.06.2022.** Mediante Informe N° 451-2022-GRA/GG-GRI-SGO-MABE-RO remite la Conformidad de la Orden de Compra N° 13-02 – ADENDA N° 01 por el monto de S/ 96,646.70.
- ✓ **22.06.2022.** Mediante Carta s/n el CONTRATISTA manifiesta su conformidad frente a la resolución contractual de la ENTIDAD y le solicita que la precise sus alcances.
- ✓ **30.06.2022.** Mediante Hoja de Cálculo de Penalidad N° 203 se evaluó la penalidad correspondiente al Adicional de la ADENDA N° 01 aplicándose la penalidad máxima del monto contractual equivalente al 10% del monto de la Prestación Adicional N° 01 (S/ 11,794.67).
- ✓ **22.07.2022.** Mediante Carta 041-2022-CE el CONTRATISTA solicita a la ENTIDAD la devolución de la Carta Fianza N° 00024660 emitida por la Financiera Credinka por el monto de S/ 11,794.67.
- ✓ **17.08.2022.** El CONSORCIO reitera su solicitud de devolución de la carta fianza.
- ✓ **22.08.2022.** La ENTIDAD remite la Carta N° 224-2022-GRA/GG-ORADM mediante la cual comunica al CONTRATISTA la improcedencia de su solicitud y que procederá a ejecutar la carta fianza.
- ✓ **02.09.2022.** Mediante Informe N° 071-2022/GRAGG-ORADM-OAPF-UPL-MVRM la responsable de penalidades de licitaciones reitera su opinión respecto a la improcedencia sobre la devolución de la carta fianza y que se ejecute la misma.

- ✓ **05.09.2022.** Mediante Oficio N° 1437-2022-GRA-/GG-ORADM-OAPF, el Director de la Oficina de Abastecimiento y Patrimonio Fiscal opina que se reitere la improcedencia sobre la devolución de la carta fianza y se ejecute la misma.
- ✓ **07.09.2022.** Mediante Carta N° 238-GRA/GG-ORADM la ENTIDAD comunica al CONTRATISTA que su solicitud de devolución de la Carta Fianza es improcedente.

69. Así pues, en el presente caso el Árbitro Único advierte que no es materia controvertida que, El CONTRATISTA otorgó como garantía de fiel cumplimiento del CONTRATO la Carta Fianza N° 010621419-00 emitida por el Banco Scotiabank, por la suma de S/47,200.00, la cual admite que no cumplió en renovar oportunamente, motivo por el cual la ENTIDAD dispuso la ejecución de la referida carta luego de resolver parcialmente el CONTRATO, conforme se dispone en la LCE, según se puede apreciar de su demanda arbitral.

> 4. Que, el Consorcio, no cumplió en renovar oportunamente la Carta fianza N° 010621419-00 emitida por el banco Scotiabank, por la suma de S/ 47,200.00, otorgado para la suscripción del contrato original. Ante ello, la Entidad dispuso la ejecución de la referida carta, conforme se dispone en la Ley de Contrataciones del Estado. Dicha situación no fue objetada por nuestra parte debido a que correspondía su ejecución; estando vigente únicamente la Carta Fianza N° 00024660 emitida por la financiera Credinka por el monto de S/ 11,794.67, otorgada como garantía para la suscripción de la adenda.

70. Tampoco existe controversia en el hecho que el CONTRATISTA otorgó la Carta Fianza N° 00024660 de la Financiera Credinka por la suma de S/11,794.67 como garantía de fiel cumplimiento al suscribirse la Prestación Adicional N° 01 del CONTRATO, el cual como mencionamos fue resuelto parcialmente por la ENTIDAD mediante Carta Notarial N° 81-2022-GRA/GG-ORADM de fecha 15.11.2022, resolución que no fue materia de cuestionamiento por el CONTRATISTA, puesto que reconoce que no pudo concluir la ejecución del servicio en su totalidad, por lo cual la resolución parcial quedó consentida.

71. Así mismo, en el presente caso el Árbitro Único advierte que, a pesar que el CONTRATISTA se comprometió legalmente a cumplir con las prestaciones en un plazo determinado no lo hizo, incurriendo en demora injustificada hasta alcanzar el máximo de la penalidad por mora (10% del monto total del contrato), por lo cual la ENTIDAD le aplicó la penalidad correspondiente, de acuerdo a lo pactado en el CONTRATO, y establecido en la LCE y el RLCE.

72. La controversia entre LAS PARTES surge al momento en que la ENTIDAD paga al CONTRATISTA el valor de los trabajos ejecutados y, siendo que la causa para la resolución parcial del CONTRATO era atribuible al CONTRATISTA, la ENTIDAD le aplicó la penalidad máxima por mora en los pagos solicitados, los cuales ascendieron a la suma de S/ 47,200.00,

correspondiente al CONTRATO PRINCIPAL y S/ 11,794.67, correspondiente a la Adenda por la Prestación Adicional N° 1, pagos que fueron deducidos en los pagos efectuados, y, además, retuvo y comunicó que ejecutaría la segunda carta fianza.

73. El CONTRATISTA al no encontrase de acuerdo, reclamó ante la ENTIDAD argumentando que, para el caso del CONTRATO PRINCIPAL, correspondía que se le pague el monto íntegro, toda vez que la garantía de fiel cumplimiento ya había sido ejecutada. Argumenta que dicho error fue subsanado por la ENTIDAD ya que el monto ejecutado fue devuelto posteriormente, sin embargo, no lo ha probado durante el proceso arbitral.

74. Con respecto a la ADENDA N° 01 por la Prestación Adicional N° 1, sostiene que la ENTIDAD cumplió con retener el 10% del monto contractual del adicional aprobado, por lo que correspondía que le realice la devolución de la Carta Fianza N° 00024660 emitida por la Financiera Credinka por el monto de S/ 11,794.67, otorgada como garantía para la suscripción de la Adenda al CONTRATO, con lo cual no cumplió, ya que mediante Carta N° 224-2022-GRA/GG-ORADM y Carta N° 238-2022-GRA/GG-ORADM, comunicó al CONTRATISTA la improcedencia de su solicitud, basándose en el Informe N° 062-2022/GRA-GG-ORADM-OAPF-UPL-MVRM e Informe N° 071-2022/GRA-GG-ORADM-OAPF-UPL-MVRM el cual recomienda ejecutar la carta fianza, por lo cual el CONTRATISTA considera que se le estaría aplicando una doble penalidad o una penalidad ascendente al 20%[10] del monto del CONTRATO o una doble penalidad, lo cual sería ilegal.

75. Por su parte, la ENTIDAD argumenta que su decisión de ejecutar la carta fianza de fiel cumplimiento de manera adicional a aplicar la penalidad se realizó conforme a lo establecido en la LCE y el RLCE, donde se plasma que la garantía de fiel cumplimiento se ejecuta, en su totalidad, cuando la resolución por la cual la Entidad resuelve el contrato por causa imputable al contratista haya quedado consentida, independientemente de la cuantificación del daño efectivamente irrogado. Por este motivo, asegura que la ejecución de la carta fianza de fiel cumplimiento obedece a lo taxativamente establecido en la normativa de la materia y se encuentra debidamente sustentada con el consentimiento de la resolución de contrato efectuada por la ENTIDAD; así como la aplicación de la penalidad máxima por mora según el cálculo de la especialista y no refutada por el CONTRATISTA. Por este motivo precisa que no se cierto que se le esté aplicando una doble penalidad al CONTRATISTA[11].

76. De acuerdo a los hechos relatados y lo alegado por LAS PARTES, corresponde analizar si en este caso la norma faculta a la ENTIDAD a retener y ejecutar la Carta Fianza N° 00024660 emitida por la Financiera

10 Audiencia Única de fecha 18 de noviembre del 2022. Video Minuto 12.00
11 Audiencia Única de fecha 18 de noviembre del 2022. Video Minuto 17.35.

Credinka por el monto de S/ 11,794.67 además de la penalidad aplicada o, por el contrario, debe proceder a devolverla según el reclamo del CONTRATISTA.

SOBRE LA PENALIDAD APLICADA AL CONTRATISTA

77. Respecto a las Penalidades, en el CONTRATO se menciona lo siguiente:

> **CLÁUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES**
>
> **Si EL CONTRATISTA** incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objet del contrato, **LA ENTIDAD** le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día d atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:
>
> $$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$
>
> Dónde:
>
> **F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;**
> **F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.**
>
> El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando **EL CONTRATISTA** acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de **LA ENTIDAD** no da lugar al pago
>
> de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 d Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
>
> Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fue necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.
>
> Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez p ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.
>
> Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otr penalidades, de ser el caso, **LA ENTIDAD** puede resolver el contrato por incumplimiento.

78. Asimismo, el RLCE establece lo siguiente:

> ***Artículo 161. Penalidades***
> *161.1. El contrato establece las penalidades aplicables al contratista ante el incumplimiento injustificado de sus obligaciones contractuales a partir de la información brindada por el área usuaria, las mismas que son objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria.*
> *161.2. La Entidad prevé en los documentos del procedimiento de selección la aplicación de la penalidad por mora; asimismo, puede prever otras penalidades. Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.*
> *161.3. En el caso de obras, dentro de las otras penalidades que se establezcan en los documentos del procedimiento, incluyen las previstas en el capítulo VI del presente título.*
> *161.4. Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta, de las valorizaciones, del pago final o en la liquidación final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.*

79. Las penalidades en la ejecución contractual, constituyen un mecanismo de resarcimiento para quien no incumplió con sus obligaciones, lo cual se genera cuando por responsabilidad de una de las partes existe atrasos en el cumplimiento de las prestaciones pactadas (penalidad por mora) o una ejecución deficiente según el objeto contractual (otras penalidades).

80. En el ámbito de las contrataciones con el Estado, la finalidad de la penalidad por mora es desincentivar el incumplimiento del CONTRATISTA, así como resarcir a la ENTIDAD por el perjuicio que el retraso en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato le hubiera causado. La ENTIDAD también está facultada a establecer "Otras penalidades" en las BASES cumpliendo con los requisitos señalados en el RLCE.

81. En opinión de ÁLVAREZ PEDROZA, la presunción legal del retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones del contrato se produce por el solo transcurso del tiempo, sin que sea necesario declarar en mora al contratista; se presume que obedece a la culpa inexcusable del contratista, en razón de lo cual, no puede probar con documentos y con el amparo del derecho, los motivos justificados del retraso. En tal sentido, el funcionario, por la sola constatación del transcurso del plazo, presume que el retraso es injustificado. Al funcionario sólo le corresponderá calificar la existencia de la demora y que ésta afecta la ejecución de las prestaciones objeto del contrato para aplicar la penalidad automáticamente. Ello quiere decir que si hay retraso se genera la penalidad bajo presunción *Iuris Tantum*[12]. Como quiera que la Entidad está sujeta a una presunción legal, en todos los casos la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la fórmula establecida. No obstante la aplicación requiere la tipificación de *injustificado*, la norma dice que la penalidad se aplica automáticamente; es decir, producido el retraso el mecanismo legal ha causado el efecto sancionador, salvo que el contratista justifique oportunamente el retraso en el cumplimiento de la ejecución de las prestaciones, objeto del contrato, caso contrario la Entidad debe aplicar la penalidad sin lugar a otorgar de derecho de explicación o defensa al contratista; a éste le corresponderá la justificación del retraso o enervarla acreditando su no configuración por no contener los elementos que la perfeccionan[13].

82. En el presente caso, tenemos que el CONTRATISTA no niega su reiterado incumplimiento respecto a sus obligaciones contractuales y asiente le hecho que debe ser sancionado por ello.

83. Frente a los hechos expuestos, debemos recordar que el CONTRATISTA afirma que la ENTIDAD le estaría cobrado una doble penalidad

---

[12] **ÁLVAREZ PEDROZA, Alejandro.** "Análisis de la Ley y Reglamento de Contrataciones del Estado – Volumen 2". Ediciones Gubernamentales 2013. Páginas 314-315.
[13] **ÁLVAREZ PEDROZA, Alejandro.** "Análisis de la Ley y Reglamento de Contrataciones del Estado – Volumen 2". Ediciones Gubernamentales 2013. Página 319.

(penalidad + retención/ejecución de la carta fianza), mientras que la ENTIDAD argumenta que sólo se aplicó lo establecido en la norma, la cual en caso de resolución de contrato imputable al CONTRATISTA la faculta para aplicarle la penalidad y además ejecutar la carta fianza.

84. Al respecto, debemos tener en cuenta que en este caso no existen dos contratos sino uno solo, ya que el CONTRATO PRINCIPAL fue ampliado con la suscripción de la ADENDA N° 01, mediante la cual se extendió el plazo de ejecución contractual y también su cuantía, la que inicialmente ascendía a S/ 470,000.00 y luego, con la suscripción de la ADENDA N° 01 por S/ 117,946.70 la cuantía del CONTRATO aumentó al monto final de **S/ 589,946.70**.

85. Esto resulta importante pues refiere que el monto total de CONTRATO VIGENTE ascendía a **S/ 589,946.70** por lo que, en caso de incumplimiento por parte del CONTRATISTA, la ENTIDAD debía aplicarle una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al 10% del monto contractual vigente, entendiéndose como **contrato vigente** al contrato original afectado por las variaciones realizadas por los reajustes, prestaciones adicionales, reducción de prestaciones, o por ampliación o reducción del plazo[14], lo cual debe ser tenido en cuenta y no considerar sólo el plazo, monto y garantías originales del CONTRATO.

86. Así, la ENTIDAD, en estricto cumplimiento de lo establecido en el CONTRATO y en la norma[15], le aplicó la penalidad máxima por mora en los pagos pendientes, los cuales ascendieron a la suma de S/ 47,200.00, correspondiente al CONTRATO PRINCIPAL y S/ 11,794.67, correspondiente a la ADENDA N° 01 por la Prestación Adicional N° 1.

87. Sin embargo, según los argumentos del CONTRATISTA, esta debería ser la única sanción a sufrir por su parte de acuerdo a lo establecido en la normativa de contrataciones con el Estado, ya que a pesar de que el CONTRATO fue resuelto por causa de este incumplimiento, niega que la sanción establecida en la norma sea, adicionalmente, la ejecución de las garantías otorgadas para garantizar el cumplimiento del CONTRATO. En ese sentido, para el CONTRATISTA se debe aplicar una u otra sanción, no las dos juntas porque sería ilegal.

88. Por tal motivo, debemos analizar lo que indica la normativa en contrataciones respecto a la resolución contractual y sus efectos.

---

[14] **ÁLVAREZ PEDROZA, Alejandro.** "Análisis de la Ley y Reglamento de Contrataciones del Estado – Volumen 2". Ediciones Gubernamentales 2013. Página 316-317.
[15] Art. 161° RLCE – Penalidades.

SOBRE LA RESOLUCIÓN CONTRACTUAL EFECTUADA POR LA ENTIDAD

89. La resolución contractual es definida por MESSINEO[16] como la extinción de un vínculo contractual válido como consecuencia de un evento sobrevenido, o de un hecho (objetivo) nuevo, o un comportamiento de la contraparte, posterior a la formación del contrato, que de algún modo altere las relaciones entre las partes tal como se habían construido originalmente o perturbe el normal desarrollo (ejecución) del contrato, de manera que este no puede continuar existiendo, porque se ha modificado, o en absoluto se ha roto, aquella composición de intereses cuya expresión constituye el contrato, y a la cual las partes han hecho referencia al celebrarlo.

90. Por su parte, MORÓN URBINA determina que "*la resolución del contrato es una forma de terminación anticipada del contrato, y se produce cuando una de las partes falta al cumplimiento de sus prestaciones, pese haber sido requerido previamente para que subsane su incumplimiento, cuando se torna imposible, de manera definitiva, su continuación por caso fortuito o fuerza mayor, o por un hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato y que este previste en la normativa.*"[17]

91. De las distintas citas puede colegirse que la resolución contractual es una institución que tiene por objeto la terminación de un vínculo jurídico de derecho público, disponiendo su ineficacia y que puede sostenerse en alguna causal, la misma que puede ser el incumplimiento de alguna de las partes, la fuerza mayor o el caso fortuito.

92. Para que el acto resolutivo surta los efectos que el ordenamiento jurídico dispone, corresponde que la parte afectada siga el procedimiento determinado por el RLCE, cuya dinámica es la siguiente:

- ✓ Un requerimiento notarial, para lo cual corresponderá otorgar un plazo para la ejecución de la prestación o prestaciones pendientes, dentro de los términos del ordenamiento, y bajo apercibimiento de declarar la resolución del contrato en caso se persista en una conducta renuente al solicitado cumplimiento; y,

- ✓ Una comunicación notarial de la decisión de resolver el contrato.

93. Debemos tener en cuenta que el requerimiento es una intimación con la cual se invita a la contraparte a cumplir en un plazo determinado bajo apercibimiento de resolución del contrato y que aun cuando el deudor no haya cumplido con la obligación requerida en el plazo acordado por el acreedor en el requerimiento, el contrato no queda

---

[16] **MESSINEO, Francesco**. Derecho Civil y Comercial. Tomo IV. Pág. 522 y Doctrina General del Contrato. Tomo II. Pág. 333.
[17] **MORÓN URBINA, Juan.** *La contratación estatal*. Lima: Gaceta Jurídica, 2016, p. 689.

resuelto de pleno derecho sino que es necesaria la voluntad del acreedor expresada en una carta notarial comunicando que, ante la no satisfacción del requerimiento, el contrato ha quedado resuelto.

94. En ese orden de ideas, cabe señalar que de conformidad con lo establecido en el Art. 1271° del Código Civil, la resolución es una acción destinada a hacer cesar los efectos de contratos afectados por vicios sobrevinientes al momento de su celebración y para alcanzar dicho objetivo jurídico, la parte que desee resolver el contrato deberá seguir estrictamente el procedimiento señalado en la norma.

95. Para el caso que nos ocupa, esta resolución contractual y su procedimiento están regulados en el artículo 36°[18] de la LCE y, en los artículos 164°[19] y 165°[20] del RLCE, concluyendo que la resolución se puede producir de tres formas:

---

[18] ***"Artículo 36° LCE. Resolución de los contratos***
36.1 Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuación del contrato, por incumplimiento de sus obligaciones conforme lo establecido en el reglamento, o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a alguna de las partes.
36.2 Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a alguna de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados. No corresponde el pago de daños y perjuicios en los casos de corrupción de funcionarios o servidores propiciada por parte del contratista, de conformidad a lo establecido en el artículo 11".

[19] ***"Artículo 164°. Causales de resolución***
164.1. La Entidad puede resolver el contrato, de conformidad con el artículo 36 de la Ley, en los casos en que el contratista:
a) Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello;
b) Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo; o
c) Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido para corregir tal situación.
164.2. El contratista puede solicitar la resolución del contrato en los casos en que la Entidad incumpla injustificadamente con el pago y/u otras obligaciones esenciales a su cargo, pese a haber sido requerida conforme al procedimiento establecido en el artículo 165.
164.3. Cualquiera de las partes puede resolver el contrato por caso fortuito, fuerza mayor o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a las partes y que imposibilite de manera definitiva la continuación de la ejecución del contrato."

[20] ***"Artículo 165°. Procedimiento de resolución de contrato***
165.1. Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada requiere mediante carta notarial que las ejecute en un plazo no mayor a cinco (5) días, bajo apercibimiento de resolver el contrato.
165.2. Dependiendo del monto contractual y de la complejidad, envergadura o sofisticación de la contratación, la Entidad puede establecer plazos mayores, pero en ningún caso mayor a quince (15) días.
En caso de ejecución de obras se otorga un plazo de quince (15) días.
165.3. Si vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, la parte perjudicada puede resolver el contrato en forma total o parcial, comunicando mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato. El contrato queda resuelto de pleno derecho a partir de la recepción de dicha comunicación.
165.4. La Entidad puede resolver el contrato sin requerir previamente el cumplimiento al contratista, cuando se deba a la acumulación del monto máximo de penalidad por mora u otras penalidades o cuando la situación de incumplimiento no pueda ser revertida. En estos casos, basta comunicar al contratista mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato.

- **Resolución sin responsabilidad de las partes:** caso fortuito o fuerza mayor que imposibilita de manera definitiva la continuación del contrato.
- **Resolución por causa atribuible a la Entidad**: incumplimiento injustificado de sus obligaciones esenciales pese haber sido requerida conforme al procedimiento establecido.
- **Resolución por causa atribuible al contratista:** por alguno de los 3 supuestos establecidos en el artículo 164° del RLCE o se incurre en las causales de resolución pactadas en el contrato

96. Asimismo, en el artículo 166° RLCE se regula cuáles son los efectos de la resolución contractual:

> **Artículo 166. Efectos de la resolución**
>
> 166.1. Si la parte perjudicada es la Entidad, esta ejecuta las garantías que el contratista hubiera otorgado sin perjuicio de la indemnización por los mayores daños irrogados.
> 166.2. Si la parte perjudicada es el contratista, la Entidad reconoce la respectiva indemnización por los daños irrogados, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad.
> 166.3. Cualquier controversia relacionada con la resolución del contrato puede ser sometida por la parte interesada a conciliación y/o arbitraje dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes de notificada la resolución. Vencido este plazo sin que se haya iniciado ninguno de estos procedimientos, se entiende que la resolución del contrato ha quedado consentida.

97. En el presente caso tenemos que inicialmente, la ENTIDAD resolvió el CONTRATO con fecha 23.09.2021 mediante Carta Notarial N° 98-2021-GRA/GG-ORAM, por acumulación de la penalidad máxima del 10% del monto contractual por retraso injustificado.

98. Sin embargo, con fecha 15.11.2021 ambas partes suscribieron un acuerdo conciliatorio mediante el cual la ENTIDAD dejaba sin efecto la resolución del CONTRATO, el CONTRATISTA acepta la aplicación de la penalidad máxima del 10% del monto contractual por retraso injustificado y la ENTIDAD otorgaba 40 días calendario más para la culminación de las actividades.

165.5. La resolución parcial solo involucra a aquella parte del contrato afectada por el incumplimiento y siempre que dicha parte sea separable e independiente del resto de las obligaciones contractuales, siempre que la resolución total del contrato pudiera afectar los intereses de la Entidad. En tal sentido, el requerimiento que se efectúe precisa con claridad qué parte del contrato queda resuelta si persistiera el incumplimiento. De no hacerse tal precisión, se entiende que la resolución es total.
165.6. Tratándose de contrataciones realizadas a través de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, toda notificación efectuada en el marco del procedimiento de resolución del contrato regulado en el presente artículo se realiza a través del módulo de catálogo electrónico."

99. Sin embargo, a pesar de esta nueva oportunidad, el CONTRATISTA incurrió en nuevos incumplimientos a sus obligaciones contractuales, por lo que cual mediante Carta Notarial N° 81-2022-GRA/GG-ORADM de fecha 16.06.2022 la ENTIDAD comunicó al CONTRATISTA la resolución parcial del CONTRATO.

100. Esta resolución contractual no fue controvertida por el CONTRATISTA quien nuevamente reconoció su infracción, limitándose a solicitar el pago correspondiente por los trabajos efectivamente realizados.

101. En tal sentido, la resolución contractual quedó consentida surtiendo plenos efectos legales, incluyendo la ejecución de garantías a favor de la ENTIDAD según lo establecido en el Art. 166° del RLCE, ya comentado.

SOBRE LA EJECUCIÓN DE LAS GARANTÍAS OTORGADAS POR EL CONTRATISTA

102. Respecto a lo establecido en el CONTRATO sobre las Garantías y su Ejecución, tenemos lo siguiente:

> **CLÁUSULA OCTAVA: GARANTÍAS**
>
> **EL CONTRATISTA**, entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solida irrevocable y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de la ENTIDAD, por conceptos, montos y vigencias siguientes:
>
> De fiel cumplimiento del contrato: S/ 47,200.00 (cuarenta y siete mil doscientos con 00/100 soles), a través la Carta Fianza N° 010621419-000 emitida por el banco Scotiabank. Monto que es equivalente al diez ciento (10 %) del monto del contrato original, la misma que debe de mantenerse vigente hasta la conformi de la recepción de la prestación. de acuerdo a lo establecido en el numeral 149.4 del articulo 149° Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
>
> **CLÁUSULA NOVENA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN**
>
> **LA ENTIDAD**, puede solicitar la ejecución de las garantías cuando el CONTRATISTA no las hub renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1 artículo 155° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

103. A fin de analizar correctamente esta pretensión debemos definir lo que son las garantías y acotar lo establecido en la norma al respecto. Así, el término garantía contiene en esencia la finalidad de brindar seguridad, protección o certeza sobre algo. En este contexto, la LCE y el RLCE, normas que tienen como objetivo principal lograr la contratación eficiente de bienes, servicios y obras para que las entidades del Sector Público puedan cumplir con sus funciones encomendadas frente a la comunidad, ha regulado las garantías que los postores y/o contratistas deben presentar durante un proceso de contratación pública.

104. Estas garantías tienen como finalidad asegurar el cumplimiento del contrato ya formalizado y las responsabilidades del contratista derivadas del mismo contando con dos finalidades:

- ✓ Compulsiva: lo que pretenden es compeler u obligar al contratista a que cumpla sus obligaciones contractuales, pues de lo contrario se haría merecedor a la ejecución de las garantías que presentó para garantizar su obligación.

- ✓ Resarcitoria: a través de su ejecución se busca indemnizar a la Entidad por los eventuales daños y perjuicios que haya sufrido debido al incumplimiento del contratista.

105. Las particularidades que deben contener las garantías a fin de que una entidad las acepte, son las siguientes:

- **Incondicionalidad:** La ejecución de la garantía que respalda la obligación hasta determinado monto, no se encuentra sujeta a condición alguna.

- **Solidaridad:** Se refiere a la responsabilidad compartida respecto al pago de la deuda; es decir, tanto el deudor (proveedor que contrata con el Estado) como el fiador (empresas que emiten la garantía), son indistintamente responsables del pago de la deuda.
  Es preciso considerar que las garantías en materia de contratación pública establecen un tope que viene a ser el monto hasta por el cual se ha garantizado determinada obligación.

- **Irrevocabilidad:** El deudor y el fiador garantizarán la obligación mientras se encuentre vigente la garantía. Por tanto, esta no puede ser anulada de manera unilateral.

- **De realización automática en el país al solo requerimiento de la Entidad:** Se refiere a la obligación que tienen las empresas emisoras de las garantías, de no oponerse a su ejecución. Deben honrarlas dentro del plazo máximo de tres (03) días; en caso contrario, generará responsabilidad solidaria, dará lugar al pago de intereses en favor de la entidad y serán sujetos de sanción por parte de la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones.

106. En materia de contrataciones del Estado, el RLCE regula las garantías y su ejecución en los siguientes artículos:

Artículo 149. Garantía de fiel cumplimiento

149.1. Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador entrega a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista, en el caso de bienes, servicios en general y consultorías en general, o hasta el consentimiento de la liquidación final, en el caso de ejecución y consultoría de obras.

Artículo 155. Ejecución de garantías

155.1 Las garantías se ejecutan en los siguientes supuestos:

a) Cuando el contratista no la hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento. Una vez que se cuente con la conformidad de la recepción de la prestación o haya quedado consentida la liquidación, según corresponda, y siempre que no existan deudas a cargo del contratista o de haber saldo a favor, se le devuelve el monto ejecutado sin dar lugar al pago de intereses. Tratándose de las garantías por adelantos, no corresponde devolución alguna por el adelanto pendiente de amortización.

b) La garantía de fiel cumplimiento se ejecuta, en su totalidad, cuando la resolución por la cual la Entidad resuelve el contrato por causa imputable al contratista haya quedado consentida o cuando por laudo arbitral se declare procedente la decisión de resolver el contrato. En estos supuestos, el monto de la garantía corresponde íntegramente a la Entidad, independientemente de la cuantificación del daño efectivamente irrogado.

107. Tal como desarrollamos en considerandos anteriores, estamos frente a un contrato ÚNICO cuya cuantía asciende a **S/ 589,946.70** y por tanto, de acuerdo a lo establecido por el RLCE, la garantía de fiel cumplimiento asciende al 10% del valor contractual vigente luego de las modificatorias, esto es, **S/ 58,994.67,** ya que la garantía original fue ampliada al incorporarse la ADENDA N° 01 al CONTRATO.

108. Que, esto se refleja en las siguientes cláusulas de la ADENDA N° 01:

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO DE LA ADENDA

El objeto de la presente adenda es incorporar la prestación adicional al CONTRATO N°0154-2020-GRA-SEDE CENTRAL-OAPF, aprobada mediante la Resolución Gerencia General N° 192-2022-GRA/GR-GG, por el monto de S/. 117,946.70 que representa el 24.98% del contrato original.

CLÁUSULA TERCERA: MODIFICACIÓN DE LA CLAUSULA CUARTA (DEL MONTO CONTRACTUAL)

El monto del contrato primigenio para la contratación de bienes **ADQUISICION E INSTALACION DEL SISTEMA DE GASES MEDICINALES; AFECTO A LA META 099 DE LA OBRA "REEMPLAZO DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DE LA RED DE SALUD HUAMANGA - AYACUCHO"** es de **S/ 472,000.00 (Cuatrocientos setenta y dos mil con 00/100 soles)** que incluye todos los impuestos de ley, bajo el sistema de contratación **de SUMA ALZADA**, con modalidad de ejecución de llave en mano.

El atención al adicional aprobado para la contratación de bienes **ADQUISICION E INSTALACION DEL SISTEMA DE GASES MEDICINALES; AFECTO A LA META 099 DE LA OBRA "REEMPLAZO DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DE LA RED DE SALUD HUAMANGA - AYACUCHO"** que asciende a **S/ 117,946.70** (Ciento diecisiete mil novecientos cuarenta y seis con 70/100 soles,) incluye todos los impuestos de ley; el **MONTO ACTUALIZADO** vendría a ser, conforme el detalle siguiente:

REPRESENTANTE COMUN

MONTO TOTAL DEL CONTRATO (PRIMIGENIO Y ADICIONAL)

DESCRIPCIÓN	MONTO	MONTO TOTAL
CONTRATO ORIGINAL	S/.472,000.00	S/. 589,946.70
ADICIONAL N° 01 **(representando el 24.98% del contrato original)**	S/.117,946.70	

CLÁUSULA CUARTA: MODIFICACIÓN DE LA CLAUSULA OCTAVA (GARANTIAS):

El contratista entregó al perfeccionamiento del contrato primigenio la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática a favor de la ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: **S/. 47,200.00 (Cuarenta y siete mil doscientos con 00/100 soles)**, a través de la carta de fianza N°010621419-000 emitida por el Banco Scotiabank. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación. De acuerdo a lo establecido en el numeral 149.4 del artículo 149° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

- En mérito a lo dispuesto en el artículo tercero de la Resolución Gerencia General N°192-2022-GRA/GR-GG, de fecha 27 de abril de 2022, para la suscripción de la presente adenda, el contratista entregó la ampliación de la garantía mediante Carta Fianza N°00024660 – cuenta N° 070-550-1178-2 emitida por la FINANCIERA CREDINKA, por el monto de **S/. 11,794.67 (Once mil setecientos noventa y cuatro con 67/100 Soles)**, monto que es equivalente al diez por ciento (10%) **del monto del Adicional aprobado**, la misma que debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación. De acuerdo a lo establecido en el numeral 149.4 del artículo 149° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

109. En esta última cláusula referida a las Garantías, nótese que en el párrafo referido a la segunda carta fianza, LAS PARTES *pactan "el contratista entregó **<u>la ampliación de la garantía</u>** mediante Carta Fianza N° 00024660 (…)"*, lo cual va en concordancia con las demás cláusulas transcritas y con el hecho de que se trata de un solo contrato,

con algunas cláusulas que están siendo modificadas por acuerdo de ambos.

110. Y esto es reconocido también por el CONTRATISTA cuando en los Puntos II.3 y II.4 de su demanda cuando menciona:

> 2. Mediante Resolución Gerencial General N° 192-2022-GRA/GR-GG, de fecha 27 de abril de 2022, se aprueba la ejecución de prestaciones adicionales al Contrato N° 154-2020-GRA-SEDE CENTRAL-OAPF, por el monto de S/ 117,946.70. Para ello, se dispuso que nuestra parte cumpla con ampliar la garantía de fiel cumplimiento, ello de conformidad con lo establecido en el art. 157 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

> 3. Para la suscripción de la Adenda N° 01 al contrato N° 154-2020-GRA-SEDE CENTRAL-OAPF, cuyo objeto fue incorporar la prestación adicional al referido contrato aprobado por el monto de S/ 117,946.70, nuestra parte otorgó como garantía de fiel cumplimiento la Carta Fianza N° 00024660 emitida por la financiera Credinka por el monto de S/ 11,794.67, ello en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado.

111. Así, en el Artículo 157° numeral 3 del RLCE respecto a la ampliación de garantías se establece:

> 157.3 En caso de adicionales corresponde que el contratista aumente de forma proporcional las garantías que hubiese otorgado, debiendo entregar la actualización del valor de la garantía correspondiente en el plazo máximo de ocho (8) días hábiles de ordenada la prestación adicional. En caso de reducciones puede solicitar la disminución en la misma proporción.

112. En tal sentido, tenemos que con la Carta Notarial N° 81-2022-GRA/GG-ORADM de fecha 16.06.2022 la ENTIDAD resuelve parcialmente el CONTRATO en su totalidad, incluyendo la ADENDA N° 1, por lo que la aplicación de la penalidad y la ejecución de las garantías correspondía realizarse sobre el monto total del CONTRATO ascendente a **S/ 589,946.70**.

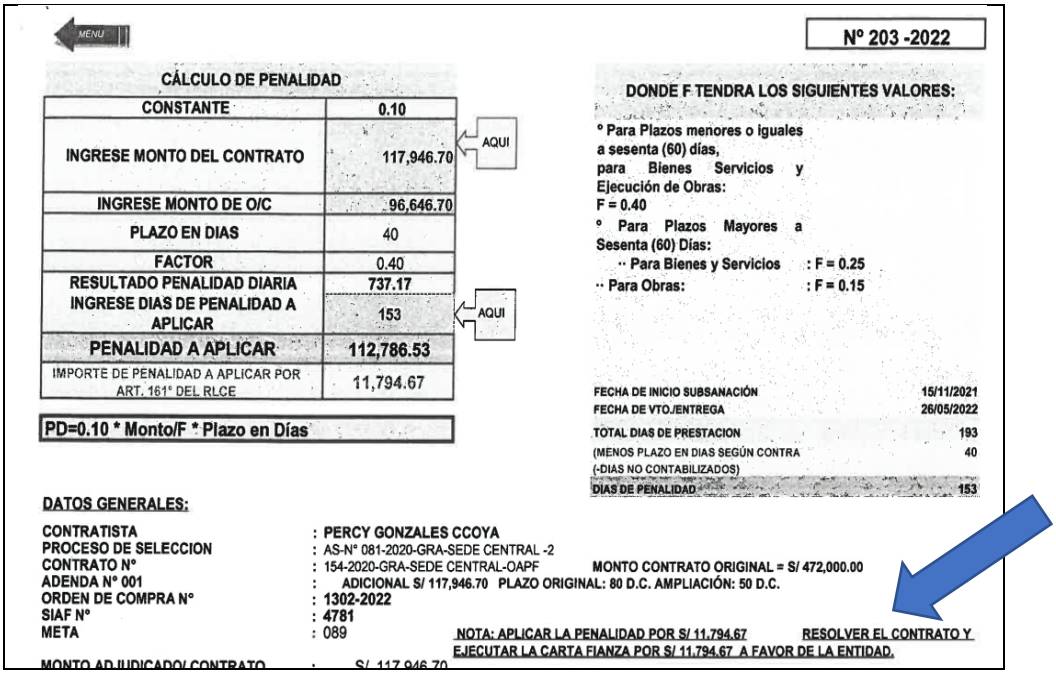
113. Es por esto que la ENTIDAD aplica al CONTRATISTA una penalidad máxima total ascendente a S/ 58,994.67 dividido en dos partes: S/ 47,200.00 y S/ 11,794.67.

114. Ahora bien, con respecto a las garantías, su ejecución está regulada en el Artículo 155° del RLCE, y en el Numeral 155.1 se señala que las mismas se ejecutan en su totalidad cuando la resolución por la

cual la ENTIDAD resuelve el contrato por causa imputable al contratista haya quedado consentida, supuesto en el cual el monto de la garantía corresponde íntegramente a la ENTIDAD, independientemente de la cuantificación del daño efectivamente irrogado.

115. En el caso bajo análisis tenemos que la ENTIDAD resolvió parcialmente el CONTRATO por causas imputables al CONTRATISTA, resolución que fue aceptada por él[21] y quedó consentida, por lo cual legalmente se debe aplicar lo establecido en el Numeral 155.1 del Artículo 155° del RLCE comentado en el considerando anterior, y ejecutar en su totalidad las garantías otorgadas, además de aplicar la penalidad correspondiente.

116. Este procedimiento legal se ve reflejado en la Hoja de Cálculo de Penalidad N° 203-2022 donde se recomienda aplicar la penalidad por S/ 11,794.67, resolver el CONTRATO y ejecutar la carta fianza por S/ 11,794.67.



MENU

N° 203 -2022

CÁLCULO DE PENALIDAD

CONSTANTE	0.10	
INGRESE MONTO DEL CONTRATO	117,946.70	AQUI
INGRESE MONTO DE O/C	96,646.70	
PLAZO EN DIAS	40	
FACTOR	0.40	
RESULTADO PENALIDAD DIARIA	737.17	
INGRESE DIAS DE PENALIDAD A APLICAR	153	AQUI
PENALIDAD A APLICAR	112,786.53	
IMPORTE DE PENALIDAD A APLICAR POR ART. 161° DEL RLCE	11,794.67	

PD=0.10 * Monto/F * Plazo en Días

DONDE F TENDRA LOS SIGUIENTES VALORES:

° Para Plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para Bienes Servicios y Ejecución de Obras:
F = 0.40
° Para Plazos Mayores a Sesenta (60) Días:
·· Para Bienes y Servicios : F = 0.25
·· Para Obras: : F = 0.15

FECHA DE INICIO SUBSANACIÓN	15/11/2021
FECHA DE VTO./ENTREGA	26/05/2022
TOTAL DIAS DE PRESTACION	193
(MENOS PLAZO EN DIAS SEGÚN CONTRA	40
(-DIAS NO CONTABILIZADOS)	
DIAS DE PENALIDAD	153

DATOS GENERALES:

CONTRATISTA : PERCY GONZALES CCOYA
PROCESO DE SELECCION : AS-N° 081-2020-GRA-SEDE CENTRAL -2
CONTRATO N° : 154-2020-GRA-SEDE CENTRAL-OAPF MONTO CONTRATO ORIGINAL = S/ 472,000.00
ADENDA N° 001 : ADICIONAL S/ 117,946.70 PLAZO ORIGINAL: 80 D.C. AMPLIACIÓN: 50 D.C.
ORDEN DE COMPRA N° : 1302-2022
SIAF N° : 4781
META : 089

NOTA: APLICAR LA PENALIDAD POR S/ 11,794.67 RESOLVER EL CONTRATO Y EJECUTAR LA CARTA FIANZA POR S/ 11,794.67 A FAVOR DE LA ENTIDAD.

MONTO ADJUDICADO/ CONTRATO : S/ 117,946.70

117. Según lo explicado, en este caso la ENTIDAD no está aplicando una doble penalidad ni el 20% del monto vigente del CONTRATO como penalidad, tal como sostiene el CONTRATISTA.

118. En efecto, según lo desarrollado anteriormente, se trata de un único contrato y la penalidad aplicada ascendente a S/ 58,994.67 refleja el 10% del monto vigente del CONTRATO, y las dos cartas de garantías otorgadas por el CONTRATISTA, las cuales en conjunto equivalen al 10% del monto vigente del CONTRATO, son ejecutadas en

[21] Audiencia Única de fecha 18 de noviembre del 2022 Minuto 8.30.

aplicación directa de la norma por el consentimiento de la resolución contractual[22].

119. Y esto también se plasma en la **Opinión N° 015-2018/DTN** de fecha 31 de enero del 2018, la cual ha sido mencionada por ambas partes en la Audiencia Única:

> *"(…)*
> *Conforme a lo anterior, habiendo la Entidad resuelto el contrato por causa imputable al contratista y ejecutado la garantía de fiel cumplimiento -como consecuencia de la resolución contractual- sin que el proveedor haya cumplido con abonar el monto máximo de penalidad por mora calculado durante la vigencia del contrato, la Entidad en su calidad de garante del interés público deberá adoptar las acciones que resulten necesarias a efectos de cobrar la penalidad por mora.*
>
> *Por tanto, si la Entidad procedió a resolver el contrato al haberse llegado a acumular el monto máximo de penalidad por mora y ante ello ejecuta la garantía de fiel cumplimiento por dicha resolución sin que se haya podido cobrar el monto de la penalidad,* ***la ejecución de la garantía no puede usarse para amortizar la referida penalidad, correspondiendo a la Entidad solicitar el pago de dicha penalidad al proveedor****."*
> (Énfasis agregado)

120. Esto refiere que el consentimiento de la resolución de contrato gatilla la ejecución de las cartas fianza del fiel cumplimiento a favor de la ENTIDAD, sin que esto impida el cobro de las penalidades acumuladas por el CONTRATISTA. No son sanciones excluyentes como lo entiende la parte demandante.

121. Por tanto, este Árbitro Único es de la opinión que el procedimiento utilizado por la ENTIDAD aplicando la penalidad máxima al CONTRATISTA por incumplimiento de obligaciones contractuales y la ejecución de las cartas fianza luego del consentimiento de la resolución contractual, está acorde a lo que establece la normativa en contrataciones con el Estado y las propias opiniones del OSCE, de acuerdo a lo establecido en los artículos 155° (Ejecución de Garantías), 161° (Penalidades) y 166° (Efectos de la Resolución) del RLCE.

122. Finalmente, respecto a que la funcionaria responsable de penalidades de la ENTIDAD no sería competente para calificar si se causó o no perjuicio a la demandada, el Árbitro Único concuerda con lo mencionado por ella en el Informe N° 071-2022/GRAGG-ORADM-OAPF-UPL-MVRM del 02.09.2022, cuando refiere que su función es opinar sobre los hechos materia de consulta, y es función de sus superiores aplicar o no sus recomendaciones. En tal sentido, el Árbitro Único advierte que la evaluación del caso por parte de la ENTIDAD

[22] Artículo 155°.1 del RLCE.

siguió el procedimiento adecuado y sus decisiones fueron emitidas por los funcionarios competentes, por lo cual deben surtir efectos legales.

123. Así las cosas, según lo explica GONZÁLEZ DE COSSÍO[23], la carga de la prueba la tiene quien asevera un hecho. Es decir, en arbitraje como en derecho procesal en general, rige la máxima *onus probando actori incumbit*. Quien sostiene un hecho debe probarlo, so pena de que se deseche su pretensión (*actore non probante reus absolvitur*) a menos que sea beneficiario de una presunción. Debe entender que le corresponde probar no al actor o al demandante desde un punto de vista procesal, sino al que afirma (*ei qui affirmat*) una pretensión o excepción y no quien lo niega (*non ei qui negat)*.

124. Que, en palabras de JOÃO PENIDO BURNIER JÚNIOR[24] al analizar el valor probatorio en un proceso: "*Lo importante, no obstante, es no olvidar que no existe* superioridad *de un medio de prueba sobre el otro, nada garantiza que un testigo que narra el hecho, que afirma haber presenciado, esté diciendo la verdad, y que otro, que describe la posición de un objeto, esté mintiendo*. ***Será el examen del conjunto probatorio, de todas las pruebas que constan en los autos, el que formará la convicción del juez en cuanto a los hechos de la causa (…)".*** (Énfasis agregado)

125. Por tanto, en mérito al apoyo de sucedáneos[25] a través de los cuales se corroboraría lo mencionado y, habiendo escuchado los hechos relatados, las declaraciones y en mérito a los aforismos *Venite and factum. Curia novit ius* ("vaya a los hechos. El Tribunal conoce el Derecho") y *Iura novit curia* ("el Tribunal conoce los derechos"), consagrados en el artículo VII del Título Preliminar tanto del Código Civil como del Código Procesal Civil, este Árbitro Único, respecto a la Primera Cuestión Controvertida derivada de la Primera Pretensión Principal de la demanda, tiene el convencimiento al **RESOLVER y DETERMINAR** que:

- **Primera Cuestión Controvertida derivada de la Primera Pretensión Principal:**
  Que, NO corresponde que el Tribunal Arbitral Unipersonal ordene al Gobierno Regional de Ayacucho cumplir con devolver la Carta Fianza N° 00024660 emitida por la Financiera Credinka por el monto de S/ 11,794.67 y sus respectivas renovaciones, otorgada a favor de la Entidad como garantía de fiel cumplimiento para la aprobación del adicional N° 01 al Contrato N° 054-2020-GRA- SEDE CENTRAL – OAPF, y, por tanto, **INFUNDADA** la Primera Pretensión de la demanda arbitral.

---

[23] **GONZÁLEZ DE COSSÍO, Francisco.** "ARBITRAJE". Editorial Porrúa. Quinta Edición. Año 2018. Pág. 671.
[24] **PENIDO BURNIER, Junior.** "*Teoria Geral da Prova*", Editora EDICAM, página. 67.
[25] **Código Procesal Civil. Artículo 275º.** "*Finalidad de los sucedáneos. Los sucedáneos son auxilios establecidos por la ley o asumidos por el juez para lograr la finalidad de los medios probatorios, corroborando, complementando o sustituyendo el valor o alcance de éstos*".

XII. SOBRE LA SEGUNDA CUESTIÓN CONTROVERTIDA DERIVADA DE LA SEGUNDA PRETENSIÓN PRINCIPAL:

- ***Segundo Cuestión Controvertida* derivada de la Segunda Pretensión Principal:**
  "Determinar si corresponde que el Tribunal Arbitral Unipersonal ordene a la Entidad pagar a favor del Consorcio los mayores costos de renovación de carta fianza otorgada como garantía de fiel cumplimiento."

POSICIÓN DEL CONTRATISTA

126. Respecto a esta pretensión, el CONTRATISTA considera que la ENTIDAD, de manera arbitraria, se niega a la devolución de la Carta Fianza N° 00024660 emitida por la Financiera Credinka por el monto de S/ 11,794.67, otorgada como garantía para la suscripción de la adenda, incluso, recomienda su ejecución.

127. Asimismo, señala para que no se ejecute la carta fianza otorgada se ha visto obligada a tener que renovarla, ya que, de no hacerlo, podía generar que se ordene su ejecución causando perjuicios irreparables para la empresa, pues todas las entidades financieras negarán la emisión de fianzas lo que derivará en la imposibilidad de seguir contratando con el Estado y, además, se estarían ejecutando las garantías dejadas en la Entidad financiera para la emisión de la carta fianza.

POSICIÓN DE LA ENTIDAD

128. Para la ENTIDAD, siendo que la ejecución de la carta fianza es válida y procedente, la demanda carece de todo sustento factico y jurídico por lo que sus pretensiones no merecen ser estimadas y, en consecuencia, tampoco correspondería que se conmine a la demandada el pago cualquier conceto adicional.

POSICIÓN DEL ÁRBITRO ÚNICO

129. Respecto a esta Segunda Cuestión Controvertida derivada de la Segunda Pretensión Principal de la demanda arbitral, y siendo que en los considerandos anteriores se resolvió INFUNDADA la Primera Pretensión Principal de la demanda arbitral, por lo que la ENTIDAD no debe cumplir con devolver la Carta Fianza N° 00024660 emitida por la Financiera Credinka por el monto de S/ 11,794.67 y sus respectivas renovaciones, la presente pretensión también debe ser desestimada.

130. Por tanto, respecto a esta Segunda Cuestión Controvertida derivada de la Segunda Pretensión Principal de la demanda, este Árbitro Único tiene el convencimiento al **RESOLVER y DETERMINAR** que:

- **Segunda Cuestión Controvertida derivada de la Primera Pretensión Principal:**
  Que, no corresponde que el Tribunal Arbitral Unipersonal ordene a la Entidad pagar a favor del Consorcio los mayores costos de renovación de carta fianza otorgada como garantía de fiel cumplimiento, y, por tanto, **INFUNDADA** la Segunda Pretensión de la demanda arbitral.

XIII. SOBRE LA TERCERA CUESTIÓN CONTROVERTIDA DERIVADA DE LA TERCERA PRETENSIÓN PRINCIPAL:

- ***Tercera Cuestión Controvertida* derivado de la Tercera Pretensión Principal:**
  "Determinar si corresponde que el Tribunal Arbitral Unipersonal ordene a la Entidad el pago de las costas y costos asumidos por el Consorcio Energy en el presente proceso arbitral."

POSICIÓN DEL CONTRATISTA

131. Respecto a esta Tercera Cuestión Controvertida el CONTRATISTA menciona que señala que al haberse acreditado que corresponde la devolución de la carta fianza y la actuación arbitraria de la ENTIDAD de negarse a devolverla, obligándolo a renovarla, corresponde que se condene a la ENTIDAD con el pago de las costas y costos asumidos, toda vez que le viene generando perjuicios económicos y obligándolo a acudir a un arbitraje para la devolución de una carta fianza cuyo monto es similar a los honorarios arbitrales.

POSICIÓN DE LA ENTIDAD

132. La ENTIDAD reitera que, siendo que la ejecución de la carta fianza es válida y procedente, la demanda carece de todo sustento factico y jurídico por lo que sus pretensiones no merecen ser estimadas y, en consecuencia, tampoco correspondería que se conmine a la demandada el pago de las costas y costos que está acarreando el presente proceso arbitral.

POSICIÓN DEL ÁRBITRO ÚNICO

133. De acuerdo al artículo 73° del Decreto Legislativo N° 1071, Ley de Arbitraje, a falta de acuerdo de las partes, los costos del arbitraje serán de cargo de la parte vencida, pudiendo el tribunal arbitral distribuir y prorratear estos costos entre las partes si es que estima que ello es razonable, teniendo en cuenta las circunstancias del caso.

134. Asimismo, en relación a las costas y costos arbitrales, el Artículo 69° del Decreto Legislativo N° 1071, Decreto Legislativo que norma el Arbitraje, a la letra regula:

> *"Artículo 69°. - Libertad para determinar costos.*
> *Las partes tienen la facultad de adoptar, ya sea directamente o por referencia a reglamentos arbitrales, reglas relativas a los costos del arbitraje. A falta de acuerdo, el tribunal arbitral dispondrá lo conveniente, con sujeción a lo dispuesto en este título."*

135. Ahora bien, estando el presente arbitraje regido por el Reglamento del CENTRO, corresponde tener en cuenta lo dispuesto en su artículo 71°:

> SECCION VIII
> COSTOS DEL ARBITRAJE
>
> Artículo 71°.-
> Costos del arbitraje
>
> Los costos de un arbitraje comprenden los siguientes conceptos:
>
> a. Los gastos administrativos del Centro, está compuesto por:
> - Tasa por presentación de la solicitud de arbitraje.
> - Tasa por designación del Árbitro.
> - Tasa administrativa del Centro.
>
> b. Los honorarios de los árbitros.
>
> c. Los honorarios y gastos de los peritos o de cualquier otra asistencia requerida por los árbitros, conforme a este Reglamento.
>
> d. Los honorarios razonables de las defensas de las partes.
>
> e. Otros gastos razonables derivados de las actuaciones arbitrales.

136. En este entendido, debe tenerse en cuenta que no existe pacto expreso entre LAS PARTES sobre la forma de imputar las costas, costos y gastos del arbitraje, y que el que el presente caso ha estado destinado a resolver una incertidumbre jurídica compleja y razonable de ser debatida en sede arbitral para la obtención de un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, el cual ha sido esencialmente jurídico, así como una discrepancia fáctica de difícil dilucidación.

137. Ante ello, se considera apropiado disponer que LAS PARTES asuman en partes iguales los costos del caso arbitral, con excepción de los honorarios por concepto de defensa legal en los que LAS PARTES hubieran incurrido o se hubieran comprometido a pagar, los mismos que serán asumidos íntegramente por cada parte.

138. De esta manera, tomando en cuenta la liquidación efectuada por la secretaría arbitral, se tiene que el monto total de los gastos arbitrales de honorarios del Árbitro Único y los gastos administrativos pagados únicamente por el CONTRATISTA fueron los siguientes:

CASO	Gastos Administrativos	Honorario Arbitral
14-2022-CCGC-CA-CECAR-AYA	**S/ 1,500.00 más IGV**	**S/ 2,100.00 más IGV**

139. A partir del cuadro detallado, se advierte que sólo el DEMANDANTE cumplió con realizar el abono del 100% del monto total correspondiente a los honorarios del Árbitro Único y los gastos administrativos de la Secretaría Arbitral del CENTRO, al haber asumido en subrogación el pago de su contraparte. Por tanto, corresponde ordenar a la ENTIDAD el reembolso correspondiente por dicho concepto.

140. Por tanto, este Árbitro Único respecto a la Tercera Cuestión Controvertida derivada de la Tercera Pretensión Principal de la demanda, tiene el convencimiento al **RESOLVER y DETERMINAR**:

- **Tercer Cuestión Controvertida derivada de la Tercera Pretensión Principal:**
  Que, se ordene a la ENTIDAD el reembolso a favor del CONTRATISTA de la suma de **S/. 1,800.00 más I.G.V**., lo cual corresponde al 50% del monto total por gastos arbitrales asumidos en subrogación por el demandante, suma que incluye los honorarios arbitrales y los gastos administrativos del CENTRO. Por consiguiente, corresponderá que ambas partes asuman los costos y costas del presente proceso por parte iguales con excepción de los honorarios por concepto de defensa legal en los que LAS PARTES hubieran incurrido o se hubieran comprometido a pagar; y por tanto **FUNDADA EN PARTE** la Tercera Pretensión Principal de la demanda arbitral.

XIV. PARTE RESOLUTIVA – FALLO

El Árbitro Único deja constancia de que ha analizado todos los argumentos de defensa expuestos y examinado las pruebas presentadas al proceso de acuerdo a las reglas de la sana crítica y al principio de libre valoración de la prueba recogido en el artículo 43º de la LEY DE ARBITRAJE y que el sentido de su decisión es el resultado de ese análisis y de su convicción sobre la controversia, al margen que algunas de las pruebas presentadas o actuadas y algunos de los argumentos esgrimidos por LAS PARTES no hayan sido expresamente citados en el presente laudo.

Por las razones expuestas, estando a los considerandos glosados, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49º y 50º de la LEY DE

ARBITRAJE, y estando a lo prescrito por las normas legales invocadas, este Tribunal Arbitral Unipersonal, en DERECHO resuelve:

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADA la Primera Pretensión Principal de la demanda arbitral, por los fundamentos que constan en la parte considerativa de este Laudo.

SEGUNDO: DECLARAR INFUNDADA la Segunda Pretensión Principal de la demanda arbitral, por los fundamentos que constan en la parte considerativa de este Laudo.

TERCERO: DECLARAR FUNDADA EN PARTE la Tercera Pretensión Principal de la demanda arbitral y que ambas partes asuman los costos y costas del presente proceso por parte iguales, por lo que **SE ORDENA** al GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO, que cumpla con reembolsar a favor del CONSORCIO ENERGY la suma de **S/. 1,800.00 más I.G.V**., lo cual corresponde al 50% del monto total por gastos arbitrales asumidos en subrogación por el demandante. Los honorarios por concepto de defensa legal en los que las partes hubieran incurrido o se hubieran comprometido a pagar deberán ser asumidos íntegramente por cada parte.

CUARTO: DISPONER que la Secretaría Arbitral notifique el presente Laudo a las partes, en sus domicilios electrónicos.

CARLOS CHRISTIAN GONZALES CABELLO
ÁRBITRO ÚNICO